

1500935-84.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500935-84.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500935-84.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315848/2021 - 01º D.P. AMERICANA, 21495414 - 01º D.P. AMERICANA, 1879/21/344 - 01º D.P. AMERICANA, 2315848 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO TORTELLI

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

LEANDRO TORTELLI está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, "caput", do Código Penal com a agravante do artigo 61, II, "h" (segunda figura), do mesmo Código Penal, acusado de no dia 19 de novembro de 2021, por volta de 13h52, na Rua Chucrí Zogbi, 123, bairro São Vito, nesta cidade, mediante grave ameaça contra a vítima C.C.G., idoso de 70 anos, ter subtraído, para ele veículo marca Fiat, modelo Uno, placa BQV3779. Na fuga, o denunciado deu causa a diversas colisões com outros veículos e se escondeu no interior de um banheiro de uma confecção na rua Paulo Chinelato, nº 293, nesta cidade, onde foi preso e posteriormente reconhecido. A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Recebida a denúncia em 07 de dezembro de 2021, fls. 101, o réu foi citado (fls. 140).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 144/145).

Em prosseguimento à instrução, foram ouvidas três vítimas e duas testemunhas comuns, além de interrogado o réu.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 184/187).

A Defesa requer a absolvição por ausência de provas. De forma remissiva, reiterava os termos da resposta à acusação (fls. 191).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é inteiramente procedente.

Houve prisão em flagrante, com apreensão de produto do crime.

Verifica-se que na fase administrativa o réu permaneceu em silêncio (fls. 18).

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lanço aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Em juízo, confessou o crime. Estava desesperado, possuía uma dívida de drogas. Na data, não estava drogado, mas estava alcoolizado. "Encheu a cara de álcool e foi em busca de arrumar um dinheiro". Conseguiu uma arma de brinquedo, um simulacro de criança (arma de bolinha). Avistou um homem chegando de carro, com a porta aberta. Enquanto a vítima estacionava o veículo, apontou a arma para ele e deu voz de assalto. Entrou no carro e fechou a porta. A vítima grudou na arma de brinquedo, caiu o simulacro. Engatou a ré no carro e saiu. Viu uma carteira no veículo e foi pegar o dinheiro. Como estava embriagado, bateu o veículo, duas ruas para baixo do local dos fatos. Ficou tonto, saiu correndo. Entrou no primeiro lugar que avistou, entrou no banheiro para se esconder. Quase dormiu no local.

A prova oral também o incriminou.

Cícero Constantino Gama, vítima, adiantou reconhecer o acusado na tele audiência. Esclareceu que foi levar os seus netos para a escola. Na volta, parou o carro para entrar em sua casa. Desembarcou do veículo, abriu o cadeado e o portão. No momento em que se virou para o seu veículo, avistou o acusado já em seu interior. O suspeito tentava dar a partida no carro. Não acreditou no que via, perguntou se era brincadeira, momento em que o réu puxou uma arma, apontando-a em sua direção. Pegou na mão do réu para desarmá-lo, ficou com metade do corpo na rua e a outra metade dentro do veículo. No momento em que a arma caiu, pegou o objeto para afastá-lo do acusado, que tentava dar a partida no veículo. Sua esposa estava no portão. O réu conseguiu ligar o veículo, mas ao invés de engatar marcha à ré, ele engatou a primeira marcha e lançou o veículo contra a mulher, que desviou para o lado. O impacto foi tão forte, que quase arreventou o seu portão. Ficou assustado por ele quase matar a sua esposa e pulou do veículo, momento em que o acusado engatou a ré e desceu a rua, batendo em quem estava pela frente. Ficou intimidado com a arma

apontada em sua direção, acreditava que seria alvejado com tiros. Somente após desarmar o réu, viu que se tratava de uma réplica. Pela fisionomia do acusado, se ele estivesse munido com uma arma de verdade, ele teria atirado. Acionou a polícia, entregou a arma para os policiais.

Roselene Bars, que acabou sendo também atingida no patrimônio pela conduta do réu, alegou que chegava em sua casa, conduzia a sua van escolar. Reduziu a velocidade para acessar a esquerda, havia um carro parado, pois a preferencial era sua. Solicitou que a condutora seguisse, pois precisava de um espaço maior para manobrar a sua van.

Reduziu a velocidade, sinalizou com seta para conversão, momento em que outro veículo colidiu contra a traseira da sua van. Não conseguiu visualizar a fisionomia do condutor do carro que causou o acidente, porque após a colisão ele saiu correndo. Apenas o viu de costas. Seu filho, vizinhos e outras pessoas correram atrás do condutor pelo bairro, mas ele apenas retornou ao local dentro da viatura. Tomou conhecimento de que o acusado roubou aquele carro envolvido no acidente, um veículo Uno, pouco antes. Durante a fuga, em alta velocidade, ele provocou o acidente ao bater contra a sua van. Com a força do impacto, sua van empurrou o carro que tinha dado passagem.

A outra vítima do episódio e fuga do réu, Roseli Cristina Martins da Mata Rovari, a seu turno, informou que era vítima de um acidente de trânsito, provocado por outro veículo. Tomou conhecimento de que o condutor tinha roubado referido carro de um senhor. O acusado colidiu contra a traseira de uma van, que por sua vez, bateu em seu veículo. Não viu o réu, já que ele saiu correndo, logo após a colisão. Não teve condições de observar as características do motorista ou sua compleição física, apenas viu quando o condutor passou correndo pelo seu carro. Não tinha condições de identificá-lo.

A testemunha Cleiton José Mariote Lopes, Guarda Municipal, recordou-se de que receberam informação, via controle, de um assalto praticado na Rua Chucrí Zogbi. Descreveram as características do suspeito. Realizaram patrulhamento pelas adjacências. Na Rua 1º de Maio, populares alertaram que um homem, com as mesmas características informadas, após colisão, entrou em uma confecção na Rua Paulo Chinelato. Averiguaram a confecção. Durante as buscas, localizaram o acusado no banheiro externo. Ele possuía as características informadas. Posteriormente, ele foi reconhecido pelo assalto e pela colisão. Leandro foi revistado e com ele foi localizada a quantia de R\$ 54,00, pertencentes à vítima do assalto. Indagado, o acusado alegou que entrou em luta corporal com a vítima e subtraiu o seu veículo. Na fuga, ele acabou perdendo, dispensou o simulacro da pistola que utilizou na prática do assalto. O simulacro teria sido adquirido de uma mulher, que morava na Rua Carioba, em troca de cinco aparelhos celulares.

Foram até o endereço em que a mulher residia, localizaram os cinco celulares que Leandro informou ter trocado pelo simulacro. Apresentaram os fatos na Central de Polícia Judiciária, e a vítima reconheceu o acusado como a pessoa que o assaltou. O acusado foi levado até o Hospital Municipal e recebeu atendimento pelos ferimentos decorrentes da colisão dos veículos. Em seguida, a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante. O acusado não aparentava estar sob o efeito de álcool ou de substâncias entorpecentes.

Ivanilse Severino da Silva Pontello, outra guarda, ratificou em uníssono a versão. Foi irradiado um roubo, ocorrido na Rua Chucrí Zogbi. O suspeito havia roubado o veículo de um casal. Entraram em luta corporal e o acusado deixou cair uma arma, mas ele conseguiu sair com o veículo. Durante o trajeto, o acusado bateu contra um caminhão. Em seguida, ele colidiu com mais três veículos, pela Rua Paulo Chinelato. Após, o réu abandonou o carro e se escondeu. Obtiveram informações a respeito das características do suspeito e o procuravam. Receberam informações de que ele havia entrado em uma confecção. Conseguiram autorização do proprietário para entrar no local, onde lograram localizar Leandro dentro do banheiro. O suspeito foi colocado dentro da viatura e levado até o local do acidente, quando Leandro foi

identificado por todos. Em seguida, foram até a residência onde ocorreu o roubo, novamente o réu foi reconhecido, a par de possuírem imagens no local. Identificaram que a arma era um simulacro. Indagado, o acusado disse que obteve a réplica com a Eliane, em troca de cinco celulares. Alegou que tinha dívidas de drogas, praticou o roubo para pagar a dívida. Não podia afirmar se o acusado estava alterado pelo uso de alguma substância ou álcool. Observou que o acusado demonstrava estar muito nervoso para pagar a dívida, falava que se não a quitasse, iria morrer. Como se nota, a prova é boa e convincente tanto quanto a ocorrência do crime quanto a autoria.

O réu confessou com detalhes a forma como agiu para roubar o automóvel da vítima, inclusive o emprego de simulacro de arma e resistência oferecida pela vítima. Na fuga, colidiu contra veículos que estavam em trânsito, evadindo-se a pé.

A vítima reafirmou a versão, inclusive sublinhando a violência excessiva com que agiu o réu, que não obstante o ameaçasse com arma (ignorava então que fosse simulacro), jogou o carro contra a sua mulher (da vítima), que estava à frente e quase a atropelou. Só não o fez porque a mulher desviou. Não inibido, tratou de engatar marcha à ré e fugir em tresloucada, inclusive colidindo contra ao menos dois veículos que estavam em regular trânsito na via pública.

Os guardas civis informaram com detalhes a forma como localizaram o réu, escondido no banheiro de um estabelecimento (confeção). Conduziram-no até o local do acidente, onde as vítimas dos danos nos veículos reconheceram o condutor do Fiat/Uno. Igualmente, teria sido conduzido até o local do roubo, onde a vítima também o reconheceu.

Assim, silente no inquérito, em Juízo confessou a autoria, detalhando a forma como agiu para perpetrar a infração.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469).

Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de corréu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

Não bastasse, com ele foi apreendido dinheiro roubado, na carteira que a vítima deixou cair no automóvel também roubado.

A apreensão do bem é elemento forte de convicção.

Tal apreensão, por si só, já justifica o entendimento no sentido de que "Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (JTACrSP 66/410).

De outro tanto, a vítima, incisivamente, incriminou-o.

Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes)." (HC 311.331/MS - Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Quinta Turma - julgado em 24/03/2015 - DJe 08/04/2015).

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO

QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 482.281/BA - Rel. Ministra Marilza Maynard - Sexta Turma - julgado em 06/05/2014 - DJe 16/05/2014).

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TJSP, Rel. Luiz Ambra, RT 732/633).

"PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima. Valor: Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o fato de a vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (RJDTCRIM 22/309, Rel. Passos de Freitas).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (TACrimSP: RJTACrim 42/235).

"A palavra da vítima é valiosa e não pode ser desconsiderada, máxime em crimes patrimoniais, quando incide sobre o proceder de desconhecidos em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes." (TACrimSP: RJTACrim 47/268).

Finalmente, os depoimentos de guardas civis, que foram extremamente diligentes, são elementos complementares e relevantes de prova.

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -

que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

O crime se consumou, na medida em que o réu despojou a vítima Cícero de seu bem, tendo a sua posse plena e desvigiada.

APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Majorado Afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e reconhecimento da modalidade tentada do delito - Impossibilidade Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida Bem delineada a incidência das majorantes reconhecidas em desfavor do acusado, assim como a consumação delitiva, que se dá com a simples inversão da posse da 'res furtiva', de acordo com a teoria da 'amotio' Prescindibilidade da posse mansa e pacífica dos bens Precedentes dos Tribunais Superiores Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos, salientada ainda a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis - Afastamento da multa imposta e isenção das custas judiciais Inadmissibilidade Pena de multa que respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, assim como no caso das custas judiciais, deve ser deduzido em sede de execução, observada, inclusive, a Lei nº 1.060/50 - Apelo não provido. Apelação Criminal nº 1501887-41.2018.8.26.0445, sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 21 de abril de 2020. SÉRGIO RIBAS Relator

"De acordo com a teoria da amotio, adotada pelas Cortes Superiores, tem-se que, com a simples inversão da posse, já está configurado o roubo consumado, não sendo, possível, portanto, reconhecer o conatus" (STJ Ministro Marco Aurélio Bellizze 5ª Turma HC nº 177.676/SP DJe 13/03/2013).

Nesse sentido a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), bem como pelo auto de entrega de fls. 14/15.

Fixação das penas.

Na primeira fase, observo que o réu tem maus antecedentes, com condenações certificadas. Apenas uma condenação será considerada para reincidência (Processo nº 0006991-47.2014.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal de Americana/SP - Art. 306 "caput" do(a) LEI 9.503/1997, transitado em julgado para a Defesa em 05/07/2017). A outra, embora apta para o mesmo fim, para evitar 'bis in idem' será considerada como circunstância judicial, evidenciando os seus maus antecedentes, de há muito.

Assim já se pacificou que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado.

"O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.". (TJDF APR 10250110093863; no mesmo sentido, STJ, HC 306.222/RS).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (NUCCI,

Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Não bastasse, agiu com violência extremada, tanto contra o dono do carro quanto contra a mulher dessa vítima, que quase foi atropelada e no mínimo ferida. Na fuga, trouxe dano patrimonial a motoristas de outros veículos, despreocupadamente, salvo com a própria intenção de se eximir de responsabilidades e manter seguro o produto do roubo.

Aumento a pena base em um quinto, portanto, por tais circunstâncias judiciais.

Na segunda, pela reincidência (vg. Processo nº 7000585-56.2012.8.26.0019 – Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 155, §4º, IV, do Código Penal; com trânsito em julgado para a Defesa em 13/07/2012, somado/unificado em 15/08/2019, sob nº 7005035-77.2014.8.26.0114, pena extinta em 13/09/2019), lembrando também se tratar de réu confesso.

A respeito da compensação da agravante genérica da reincidência (ainda que específica) com a atenuante da confissão, por respeito aos precedentes, este Juízo aplica o quanto definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, em 2013, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 585), a Terceira Seção estabeleceu a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp.1.341.370).

Só se tem excepcionado a multirreincidência:

“Mais recentemente, em outubro do ano passado, a Terceira Seção decidiu revisar o Tema 585 para avaliar a necessidade de adequação da tese à hipótese de multirreincidência, com delimitação dos efeitos da compensação para as duas espécies de reincidência (genérica e específica). A proposta de revisão ainda não foi julgada.

Ao decidir reanalisar o precedente qualificado, o ministro Sebastião Reis Júnior apontou que o tema continua sendo objeto de grande controvérsia, tanto nas instâncias ordinárias quanto no STJ, sendo possível encontrar quase 300 acórdãos da corte superior sobre o tema e outras 6 mil decisões monocráticas (REsp 1.947.845).

Em um desses julgamentos, no HC 365.963, a Terceira Seção definiu que a reincidência específica também pode ser compensada com a confissão espontânea no cálculo da pena. A análise se deu em ação penal pelo crime de roubo, na qual o Tribunal de Justiça de São Paulo havia afastado a incidência da atenuante da confissão por entender que ela teria sido parcial, não alcançando relevância para esclarecer a dinâmica dos fatos.

O relator do habeas corpus, ministro Felix Fischer, explicou que o STJ tem jurisprudência no sentido de que é possível reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP independentemente da extensão da confissão, especialmente nos casos em que ela é utilizada como base para a condenação.

Para o magistrado, seria possível compensar a confissão com o gênero reincidência, gerando seus efeitos para ambas as espécies – genérica e específica –, ressalvados os casos de multirreincidência.”. (ESPECIAL 06/03/2022 A interpretação do STJ sobre compensação entre agravantes e atenuantes no cálculo da pena, <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/06032022-A-interpretacao-do-STJ-sobre-compensacao-entre-agravantes-e-atenuantes-no-calculo-da-pena.aspx>).

É cediço que nem todo o processo alcança todas as Instâncias Superiores, daí a relevância do respeito aos precedentes, que nada mais busca senão a garantia da estabilidade jurídica.

Por esse motivo, compenso a reincidência certificada com a atenuante da confissão espontânea. Porém, ainda nesta segunda fase, pela condição de idoso da vítima Cícero (artigo 61, II, “h”, aumento a pena em 1/6 (um sexto)).

Na terceira fase, à mingua de causas gerais de aumento e diminuição previstas na parte Geral do Código Penal (arts. 16, 21, 24, § 2º, 26, parágrafo único, 28, § 2º, 29, §§1º e 2º), ou especiais, previstas na Parte Especial do Código, adoto a pena fixada em segunda fase como definitiva aplicada.

Fixo regime fechado para cumprimento da pena, mercê da gravidade inata ao crime de roubo, incompatível com qualquer outro regime, além de ser o réu reincidente. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar a LEANDRO TORTELLI às penas de cinco (05) anos, sete (07) meses e seis (06) dias de reclusão, regime inicial fechado e quatorze (14) dias-multa, piso, por infração ao artigo 157, "caput", c.c. art. 61, I, II, 'h'; 65, III, 'd', todos do Código Penal.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório. O réu responde aos atos do processo recluso. A pena fixada é para cumprimento no regime fechado. O crime é grave e os antecedentes do réu revelam a previsibilidade de, solto, reiterar na prática de infrações.

Não é coerente, agora sentenciado o processo, que se faculte recurso em liberdade, pois persistem os motivos que ensejaram a custódia preventiva, com especial interesse agora na eficaz aplicação da lei penal.

Constatada a superveniência de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, não se vislumbra constrangimento ilegal na negativa do recurso em liberdade. Afinal, o encerramento da instância ordinária torna temerário desconstituir a custódia cautelar de Paciente preso desde o início da instrução, por decreto prisional devidamente fundamentado. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 282.074/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 29/05/2014).

De fato, tanto no C. STF quanto no C. STJ, orientam-se no sentido de que o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, não tem direito de apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar (cf: HC 333.703/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015 e HC 276.885/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

Recomende-se ao réu.

Isento o réu de custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 141).

Não faculto recurso em liberdade, pois, mantendo a prisão preventiva, recomendando-se o réu na prisão onde se encontra.

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 29 de abril de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA